

1500168-73.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... seja, a associação destinada ao financiamento do tráfico de drogas.

Nesse tipo penal, ao contrário do que exige o "caput", a exigência literal que a associação seja reiterada, ou seja, a associação para o financiamento do tráfico de drogas exige inequivocamente estabilidade e permanência, ao passo que a associação para o tráfico de droga poderá ser eventual.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 3125-4133, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat4@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500168-73.2021.8.26.0621 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATAN WILLIAM RAIMUNDO e outro

CONCLUSÃO

Aos 09 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, DR. WALTER EMÍDIO DA SILVA.

Eu, Walter Emídio da Silva, digitei.

VISTOS

WILLIAN FELIPE SIQUEIRA SILVA e JONATAN WILLIAN RAIMUNDO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", combinado com o inciso III do artigo 40, todos da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 19:10 hs, na Rua Professo Gastão Straing n. 17, Jardim Tamandaré e, na sequência, e, um terreno no mesmo Bairro, proximidade da Creche "Luzia Modesto Reis" e Escola municipal EMEIEF "Zezé Figueiredo", nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de consumo de terceiros, 156,16 gramas de cocaína, 50,5 gramas de crack e 651,58 gramas de maconha, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 18/20, laudo de constatação provisória (fls. 95/100) e laudo de exame químico toxicológico inserto em fls.180/183. Os acusados foram presos e autuados em flagrante delito.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os réus foram notificados e apresentaram suas defesas preliminares (219/225 e 250/259).

A denúncia foi recebidas em 20 de outubro 2021 (fls.266/271).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação (policiais Silva, Ribeiro e Vieira) e duas testemunhas arroladas pela defesa (Roseli de Souza e Claudinéia Oliveira, sendo, ao final, interrogados os réus.

Vencida a fase do artigo 402 do C.P.P., a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a procedência da ação penal nos exatos termos da denuncia (fls. 340/349).

A defesa do acusado Willian (fls.353/368) , pediu a absolvição pela ausência de provas de ter o acusado concorrido para a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 386, V ou VII do CPP.

Alternativamente, em caso de condenação, pediu a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixando a pena no mínimo legal. Pediu a absolvição do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso II do C.P.P. Pediu, ainda, o não reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06. O direito do acusado apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do C.P.P.

O doutor defensor do acusado JONATAN WILLIAN (fls. 371/381), postulou a absolvição do seu patrocinado, no concernente aos crimes de tráfico de drogas e associação, nos termos do artigo 386, inciso II e V do C.P.P. Alternativamente pediu: a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Tóxico; aplicação de pena mínima, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do C.P.; postulou a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que seja concedido ao acusado os benefícios da gratuidade judiciária.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico dito praticado pelos réus que teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e, agindo em concurso e unidade de desígnios e identidade de propósitos, estariam trazendo, guardando e mantendo em depósito, para fins de consumo de terceiros, 156,16 gramas de cocaína, 50,5 gramas de crack e 651,58 gramas de maconha, drogas estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fls. 18/20), laudo de constatação provisória (fls. 98/103) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 183/186).

Ausentes preliminares, quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas e periciadas como sendo realmente as drogas em questão, qual seja, cocaína, crack e maconha, prévia e definitivamente, de acordo com o Auto de Constatação de Substância Entorpecente (98/103) e laudo químico toxicológico (págs. 183/188).

A autoria e a reprovabilidade da conduta dos acusados encontram-se suficientemente comprovadas nos autos.

O acusado Willian, foi interrogado em duas oportunidades, na policia (fls.11/12) e em juízo.

Na polícia (fls. 11/12) asseverou que: " exerce a profissão de motoboy, contudo no momento encontra-se desempregado, esclarecendo também que é solteiro e não presta auxílio financeiro a ninguém. Que reconhece a Dra. Joana Rafaela Lucas da Silva Fernandes, OAB número 393739 como sua advogada, para acompanhar este ato, sendo também dado conhecimento de sua prisão à sua irmã Ingrid Paula Siqueira. Indagado a respeito da conduta dos policiais militares (abordagem e demais procedimentos) alegou que ao seu ver houve arbitrariedade , pois teve seu braço direito torcido, sendo certo que este braço encontra-se já quebrado em virtude de um disparo de arma de fogo, assim entende que houve abuso por parte dos policiais. Também adentraram na sua residência, sem mandado judicial, o que pode ser atestado por sua advogada

que estava presente no ato, explicando que o tenente indagou de sua advogada quem ela era e exigiu a apresentação da OAB, e enquanto ela dirigiu-se para o carro a fim de pegar o documento, os policiais adentraram sua residência sem ordem judicial. Ciente da versão apresentada pelos policiais militares, passou a responder sobre os fatos propriamente ditos, e negou veementemente a versão apresentada pelos milicianos. Explicando inicialmente que foi abordado na rua Gastão Strang, próximo a sua casa, e de fato estava com trezentos reais. Que de fato foi revistado mas nada foi encontrado, o que pode ser comprovado por meio de testemunhas que apresentará em momento oportuno entre elas Fernanda Lira de Oliveira e por câmeras que se encontram no local, e que poderá ser objeto de análise em momento oportuno. Logo a seguir como já narrado acima entraram em sua residência, sem ordem judicial e nada foi encontrado, depois foi levado até o terreno citado no depoimento, que fica na rua Inglês de Sousa, percebendo que Jonatan já estava dentro da viatura, e ali procuraram por aproximadamente 30 minutos e informaram à sua advogada que encontraram umas coisas. Ainda dando continuidade foram a um outro terreno ao lado da praça na rua Tamandaré e pelo que sabe nada foi encontrado. Percebeu que os policiais se reuniram e conversaram entre si, mas não sabe dizer qual foi o assunto."

Em Juízo, o acusado Willian, ao ser interrogado, "asseverou que não praticou o delito a ele imputado. Disse que a acusação é injusta. Aduziu que retornava da casa de sua irmã. Sustentou que nas proximidades de sua casa foi abordado por três policiais. Salientou que enquanto conversava com um dos policiais, os outros dois chegaram conduzindo Jonatan na viatura. Disse que eles passaram a indagar sobre os traficantes do bairro. Afirmou que os policiais queriam a indicação da casa de um traficante. Respondeu para os policiais que não sabia. Disse que foi ameaçado pelos policiais. Asseverou que os policiais disseram que se não indicasse a casa de um traficante, ele seria incriminado pela droga que estava na viatura. Aduziu que sua advogada chegou e questionou os policiais sobre o que tinha sido encontrado dele. Afirmou que os policiais responderam negativamente. Disse que os policiais foram alertados pela advogada de que eles não poderiam entrar na casa sem um mandado. Salientou que os policiais ignoraram a advertência da advogada e entraram na casa. Aduziu que nada foi encontrado em sua residência. Afirmou que foi levado até a frente de um terreno baldio. Relatou que os policiais ingressaram neste terreno e voltaram com uma mochila. Sustentou que os policiais foram em outra mata, onde nada foi encontrado. Disse que foi levado para a delegacia. Salientou que na delegacia pediu para buscarem as imagens das câmeras de segurança da escola e da creche. Afirmou que as imagens provaria que o flagrante foi forjado. Confirmou que esta sendo processado por homicídio (fls. 335/336)".

O acusado Jonatan Willian Raimundo foi interrogado em duas oportunidades, na polícia (fls. 13/14) e em Juízo .

Na polícia o acusado Jonatan asseverou: " Que tem como ofício a profissão de servente de pedreiro mas no momento encontra-se desempregado, esclarecendo que não possui dependentes nem presta auxílio financeiro a ninguém. Que reconhece a Dra. Joana Rafaela Lucas da Silva Fernandes, como sua advogada constituída para acompanhar este ato, esclarecendo que sua genitora a Sra. Regina esta ciente de sua prisão. Indagado a respeito da autuação dos policiais militares, relatou que a seu ver houve abuso na abordagem, pois inicialmente levaram a mão ao seu pescoço e quando tentou retirar, houve uma reação mais intensa sendo puxado seu cabelo, e com não concordava com a forma da abordagem acabou sendo jogado ao chão e algemado, explicou que foi enforcado por quatro vezes antes do desfecho final. Com relação aos atos esclarece que foi abordado na rua Raulino José da Silveira, em frente a casa do policial "MAURO", onde segundo o interrogando há uma câmera de segurança, que pode ser verificada. Como já disse foi enforcado e a alegação dos policiais e que ele não sabia conversar e que estaria resistindo, mas que durante a revista pessoal , somente foi encontrado um cachimbo e uma pedra de crack, nada sabendo informar sobre a origem dos 16 pinos que os policiais dizem serem seus, acrescentando que após varias negativas os policiais lhe disseram já que você não sabe, então aqui esta o entorpecente que estava no seu bolso. Lembra-se que perguntavam " onde esta, onde está", ao que respondeu que não sabia e que se

soubesse diria. Foi colocado na viatura e levado para a rua Gastão Strang, e lá continuavam perguntando sobre a droga, ao que sempre afirmava que não sabia, e eles diziam que o Felipe já havia dito que era sua. Em seguida foram levados para a rua Inglês de Sousa onde foram informados sobre o encontro de entorpecentes, houve novas buscas na rua do Tamandaré, mas pelo que soube nada foi encontrado ". Em Juízo, o acusado Jonatan negou a prática delitiva que lhe é imputada. " Asseverou que , no dia dos fatos, estava na casa de um amigo fazendo uso de drogas. Aduziu que voltava para casa, com algumas pedras de crack. Disse que foi abordado pela polícia. Afirmou que não tentou fugir. Disse que estava numa decida e que sua bicicleta não tinha freio. Salientou que foi ameaçado de morte pelos policiais. Asseverou que os policiais queriam saber onde estavam as armas e os entorpecentes. Mencionou que conhece o corréu Willian apenas de vista". As negativas dos acusados, no entanto, não encontraram ressonância na prova dos autos.

Assim é que os policiais militares desde a fase policial, de forma coesa e harmônica, relataram, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, que apontam para os réus as práticas delitivas descritas na denúncia.

Os policiais militares Wellington Rafael Félix da Silva, Flávio Henrique Ribeiro e Alexandre da Silva Vieira (fls. 33/335), relataram, a uma só voz, que, no dia dos fatos faziam patrulhamento de rotina pelo Bairro Tamandaré. Disseram que viram o acusado Willian saindo de um terreno baldio. Salientaram que o acusado ao notar a presença da polícia, montou em sua bicicleta e saiu rapidamente. Aduziram que ele foi abordado e revistado. Disseram que no bolso da bermuda do acusado foram encontrados 20 pinos de cocaína e R\$ 300,0 reais em dinheiro. Confirmaram que o acusado negou a prática do tráfico. Asseveraram que o acusado Willian disse que estava levando a droga para Jonatan, que estava nas imediações traficando.

Afirmaram que o acusado Willian deu a localização de Jonatan e suas características. Afirmaram que os policiais foram até o local indicado por Willian e lá prenderam Jonatan que portava porções de crack. Salientaram que Willian indicou o local onde havia mais drogas em uma mochila sob um sofá. Salientaram que no local indicado foi encontrada a mochila , contendo porções de crack, cocaína e maconha e duas balanças de precisão. Aduziram que não conheciam os acusado e que também não realizaram diligências na casa do acusado Willian".

Ressalte-se que as versões apresentadas pelos milicianos, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, são harmônicas e encontraram suporte nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A reiteração criminosa dos acusados (reincidentes) demonstra que os policiais militares em nenhum momento forjaram o flagrante dos acusados.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manterem a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte deles, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

De mais a mais, o agentes policiais executando suas funções após prestarem compromisso de servirem fielmente à causa pública, não podem ter os seus testemunhos tido como tendenciosos, só em razão de seus ofícios. Qualquer pessoa pode ser testemunha (art. 202 do CPP). Negar ao policial tal condição representaria evidente ofensa ao princípio constitucional da isonomia, no sentido de que eles seriam considerados pessoas de categoria inferior, com o odioso preconceito de que estariam, sempre, com o intuito de prejudicar inocentes.

Não se pode perder de vista, que os depoimentos dos agentes policiais são de vital importância, mormente em delitos deste jaez, aliás, "como servidores públicos que

são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando proibidos de depor sobre atos de ofício, de cuja fase policial tenham participado" (RJTJSP 93/400 e 95/468). As testemunhas arroladas pela defesa Roseli e Claudinéia, em nada contribuíram para melhor elucidação dos fatos.

A testemunha Roseli, ouvida sob o crivo do contraditório, asseverou que conhece somente o acusado WILLIAN. Disse que no dia dos fatos retornava da casa de sua irmã, quando viu uma viatura policial. Aduziu que a viatura estava na contramão de direção em perseguição ao acusado Willian. Salientou que tem conhecimento do envolvimento do acusado em atividades criminosas. Aduziu que Willian nunca reclamou de estar sofrendo perseguição policial (p. 335/336).

A testemunha Claudinéia, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou não conhecer os réus. Disse que, no dia dos fatos, quando se dirigia a casa de uma amiga, viu uma aglomeração de pessoas próximas a uma viatura policial. Aduziu que viu o acusado Willian no interior da viatura. Afirmou que a advogada de Willian fazia perguntas aos policiais. Disse que os policiais disseram que nada tinha sido encontrado com Willian. Sustentou que viu a advogada reclamando do ingresso dos policiais na residência de um dos acusados sem mandado judicial. Asseverou que havia muita gente no local. Relatou que o acusado Jonatan estava em outra viatura (audiovisual a pg. 335/336).

Como se vê, não há dúvida nenhuma de que as referidas testemunhas vieram a juízo com o firme propósito de tornar dúbia a prova colhida e dar suporte a tese defensiva de perseguição ilícita e abuso de autoridade. Entretanto, tais depoimentos em nada abalou o conjunto probatório, que é firme e coeso no sentido de que os réus estavam associados para o tráfico de drogas.

De mais a mais, não se pode perder de vista que os réus foram presos e autuados em flagrante em locais conhecidos como ponto de venda de drogas. Com a investida da polícia tentaram se esquivar da ação policial, oportunidade em que Jonatan teve que ser algemado. Tanto Jonatan quanto Willian foram flagrados de posse de porções de cocaína, cujo montante não condiz com a condição mero usuários. A quantidade e maneira como estavam embaladas as drogas apreendidas, demonstra que se destinavam ao tráfico e não para uso próprio.

Ressalte-se também que nos autos não existe nenhum elemento de prova capaz de colocar em dúvida, como quis fazer crer a defesa, a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado JONATAS por dependência química.

A defesa, durante todo o processado, em momento algum, pediu a instauração de incidente de insanidade mental.

Não se pode olvidar ainda que, em local indicado por Willian, foi encontrado grande quantidade e variedade de drogas numa mochila preta, bem como apetrechos típicos da mercancia ilícita de entorpecentes, como balanças de precisão e sacos plásticos. Logo é indubitável que os réus estavam associados para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Cumpra observar que o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza múltipla, ou seja, sua tipificação descreve mais de uma conduta, em relação à mesma vítima, que neste caso é a saúde pública. Essa classificação é de suma importância, pois o tráfico não consiste em apenas no ato de vender drogas a alguém.

Nota-se que os policiais militares foram categóricos ao dizerem que encontraram as drogas descritas na exordial, com os acusados e no local que o acusado Willian a eles indicou..

Igualmente, os depoimentos dos milicianos estão em conformidade com o que foi apreendido, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão às páginas (fls.18/20).

Em que pese os réus em seus interrogatórios terem negado a prática criminosa, afirmando que não estavam realizando a traficância, tais versões são desprovidas de qualquer elemento probatório contido nos autos e, por tal razão, não merecem prosperar, pois vão de encontro às provas já produzidas neste.

Seria um contrassenso, portanto, acreditar nas versões desconexas da realidade e desprovidas de qualquer prova apresentada pelos acusados e simplesmente desprezar o depoimento dos agentes policiais, posto que estes estão a serviço do Estado para

garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública.

Deste modo, observo que as características da traficância pelos Réus restaram devidamente comprovadas.

Assim, as alegações das Defesas, em que pese a elogiável apurada técnica dos Doutores Defensores, caem no vazio e em nada alteram a certeza sobre a dinâmica dos fatos e a verdade delituosa ora analisando.

Importante lembrar que, conforme é de sabença geral, os agentes policiais não existem para "caçar" aquelas pessoas que não possuem bons antecedentes, existem, sim, para combater a ilicitude e manter a ordem pública.

Neste sentido, vejamos o que preceituado pela Carta Magna de 1988:

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.(...)§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim sendo, impossível os policiais militares terem perseguido os acusados simplesmente por mera opção de tentativa de pegar um inocente.

Quanto à tipicidade tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Exatamente o que aconteceu no caso, pois nenhuma dúvida há sobre a conduta ilícita dos Réus, consoante documentos e testemunhos carreados ao bojo dos autos..

Logo, a condenação se impõe e a pena a ser aplicada deve ser a prevista para o crime de tráfico, ou seja, mais precisamente a do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 do Código Penal.

Finalmente, quanto à análise do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, observo que este encontrou suporte probatório nos autos, conforme será visto linhas a seguir.

É indubitável que os réus estavam associados (artigo 35 "caput" da Lei 11.343/2006).

No passado muito se discutia acerca do crime de associação e do concurso de agentes. Com a edição da Lei 11.343/2006, as controvérsias que existiam com referência ao crime de associação para fins de tráfico foram dissipadas, ou seja, "os elementos gramaticais ou literais do artigo 14 da Lei n. 6.368/76 eram e são claros, ou seja, dever-se-ia punir a associação eventual e não eventual, uma vez prevista, como elemento do tipo, a locução "reiteradamente ou não".

O artigo 18, inciso III da Lei acima referida, também estabelecia causa de aumento de pena em razão da mesma circunstância.

Destarte, indiscutível que eram normas conflitantes. Assim, objetivando compatibilizar tais normas passou-se a interpretar o artigo 14 da Lei 6.368/76, tal qual o crime de quadrilha, exigindo-se estabilidade e permanência para o tráfico de drogas.

Com o advento da Lei 11.343/06 esse quadro normativo sofreu mudanças, uma vez que foi revogada a causa de aumento de pena prevista no regime anterior (Artigo 18, III), o que se deu com o único propósito de se resolver o conflito de normas acima

mencionado, ou seja, aquele havido entre os artigos 14 e 18, III, da Lei 6.368/76. Com o novo regime, não há motivo para se ignorar os elementos do tipo penal albergado no Artigo 35 da Lei 11.343/06, em especial, a locução "reiteradamente ou não", pois, o que não é reiterado somente pode ser eventual e o que é eventual não exige estabilidade de permanência.

Reforça esse entendimento a descrição típica do artigo 35 parágrafo único, que estabeleceu um tipo especial de associação, qual seja, a associação destinada ao financiamento do tráfico de drogas.

Nesse tipo penal, ao contrário do que exige o "caput", a exigência literal que a associação seja reiterada, ou seja, a associação para o financiamento do tráfico de drogas exige inequivocamente estabilidade e permanência, ao passo que a associação para o tráfico de droga poderá ser eventual.

A conclusão ainda se robustece quando atentamos para a pena em abstrato cominada para o financiamento para o tráfico de drogas, que já equivale as penas de tráfico e associação somadas sem prejuízo, a despeito da clareza dos elementos do tipo e do óbvio propósito de se sanar um conflito anterior de normas, a doutrina pátria continua a dar a mesma interpretação para o artigo 35 da lei 11.343/06, ou seja, continua a exigir estabilidade ou permanência não prevista no tipo penal. Na realidade, o crime de quadrilha ou bando, nada tem a ver com a associação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06.

O artigo 35 estabelece que basta a associação reiterada ou não, para a prática do tráfico de drogas, ou seja, basta a associação eventual para a prática de um delito de tráfico de drogas para configuração do crime.

Não se exige, em momento algum, a exemplo do crime de quadrilha ou bando, que os agentes se reúnam para a prática de crimes, ou seja, para a prática de mais de um crime.

Quisesse a lei excluir o alcance do artigo 35 "caput", a simples co-autoria para o tráfico também o teria feito claramente deixando de consignar a expressão "ou não". Entretanto assim, não agiu o legislador, inarredável a conclusão de que o concurso eventual de agentes para traficância se amolda ao artigo 35 caput da lei 11.343/06".

Como se vê, os elementos de prova coligidos para os autos são mais do que suficientes para alicerçar um decreto condenatório, pois Willian, ao ser abordado pelos policiais, confessou que estava trabalhando para o correu Jonatan.

Diante disso, procedente o pedido constante na exordial quanto ao pedido de condenação dos acusados como incurso no delito de associação supracitado.

Não se pode perder de vista que o laudo (fls. 215/216) comprova a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, demonstrando que o delito se desenvolvia nas imediações de uma creche e uma escola de ensino médio. Logo, caracterizada a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, a sua incidência é de rigor, até porque a legislação não exige que o destinatário da traficância sejam os alunos da unidade escolar, mas somente a proximidade do estabelecimento (RT 607/304).

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, ação penal é procedente, não merecendo prosperar as teses apresentadas pelas defesas dos acusados, as quais foram devidamente afastadas pelas fundamentação supra.

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

CUIDO DAS SANÇÕES

Considerando e atendendo à culpabilidade dos Réus, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular aos tipos penais e pauta; à conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-la, uma vez que diz respeito tão-só à forma com que os Réus se relacionavam com seus pares no meio em que vivem; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica dos Réus; aos motivos dos crimes, não há especificação quanto aos motivos que os levaram aos delitos, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor dos

Réus; às circunstâncias dos crimes, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade desses tipos de delitos; às consequências do crimes, são de extrema gravidade, principalmente para os próprios Réus, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza, e às consequências dos crimes, não escapam à normalidade em casos da natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento das vítimas, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás, a coletividade é que é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública).

Por outro lado, a natureza e a quantidade de droga apreendida merece consideração, de maneira preponderante (art. 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, havendo uma graduação de penas, é evidente que as penas a serem impostas aos acusados devem ficar acima do mínimo legal, em razão da nocividade das drogas apreendidas, ou seja, cocaína e crack, que envolve interesses de grupos altamente perigosos, que para a sua difusão se organizam, patrocinando "chacinas", segundo diariamente noticiado nos jornais. É indiscutível que a cocaína e o crack apresentam um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano à vida e saúde das pessoas. A cocaína e o crack frequentemente levam à morte, além de serem a porta para outros tipos de tóxicos ainda mais graves, como a heroína, por exemplo.

Assim, as penas devem ficar acima do mínimo legal, ou seja:

1- Acusado WILLIAN FELIPE SIQUEIRA SILVA

A) pela prática do crime previsto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/2006, fixo a pena privativa de liberdade em CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583), dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

O acusado é reincidente (FLS. 116/118), motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para SEIS (06) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária para SEISCENTOS E OITENTA (680) dias multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, ficou devidamente caracterizada, motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para OITO(08) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS (793) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Não havendo outras causas de aumento das penas-base, tomo-as definitivas.

B) pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, fixo a pena privativa de liberdade em TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em OITOCENTOS E DEZESSETE (817) dias multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

O acusado é reincidente (FLS. 116/118), motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para QUATRO (04) ANOS E UM (1) MÊS DE RECLUSÃO e a pena pecuniária para NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS (953) dias multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, ficou devidamente caracterizada, motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para QUATRO (04) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL CENTO E DOZE (1112) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Não havendo outras causas de aumento das penas-base, tomo-as definitivas.

2- Acusado JONATAN WILLIAM RAIMUNDO

A) pela prática do crime previsto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/2006, fixo a pena privativa de liberdade em SEIS (06) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em SEISCENTOS E SESENTA E SETE (667), dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

O acusado é reincidente específico, contando com três condenações por tráfico de drogas (fls. 104/106), motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para OITO (08) ANOS E ONZE (11) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em OITOCENTOS E OITENTA E NOVE (889) DIAS-MULTA, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006,

ficou devidamente caracterizada, motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para ONZE (11) ANOS, DEZ (10) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL CENTO E OITENTA E CINCO (1185) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Não havendo outras causas de aumento das penas-base, tomo-as definitivas.

B) pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, fixo a pena privativa de liberdade em QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS (933) dias multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

O acusado é reincidente específico, contando com três condenações por tráfico de drogas (fls. 104/106), motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO (1244) DIAS-MULTA, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, ficou devidamente caracterizada, motivo pelo qual elevo a pena privativa de liberdade para SETE (07) ANOS UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE (1659) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Não havendo outras causas de aumento das penas-base, tomo-as definitivas.

Saliento que os Réus não fazem jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/06, levando em conta a quantidade e variedade da droga apreendida, o fato de estarem associados à traficância, bem como por serem reincidentes.

Posto isso e, considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA, para declarar:

A) o acusado WILLIAN FELIPE SIQUEIRA SILVA

1- como incurso nas pena do artigo 33 " caput" da Lei 11.343/2006, e, consequência, CONDENÁ-LO a pena privativa de liberdade que fixo em OITO(08) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS (793) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

2- como incurso nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/2006, e em consequência, CONDENÁ-LO a pena privativa de liberdade, que fixo em QUATRO (04) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL CENTO E DOZE (1112) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato e

B) Acusado JONATAN WILLIAM RAIMUNDO

1- como incurso nas penas do artigo 33 " caput" da Lei 11.343/2006 e, em consequência, CONDENÁ-LO a pena privativa de liberdade que fixo em e ONZE (11) ANOS, DEZ (10) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL CENTO E OITENTA E CINCO (1185) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato e

2-como incurso nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/2006, e, em consequência, CONDENÁ-LO a pena privativa de liberdade, que fixo em SETE (07) ANOS UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE (1659) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, então, os cumprimentos das penas se darão dessa forma.

Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento.

Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório e etc.). Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo - (examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave do Réu preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Não se apresenta possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal).

Pelo quantum da pena imposta, impedida a obtenção do benefício (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal).

Considerando que os Réus responderam a todo o processo presos, assim continuarão, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional, sendo muito possível que uma vez soltos voltem ao tráfico ou até fujam do distrito da culpa, dificultando ou impedindo o cumprimento da pretensão executória estatal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram presos..

Após o trânsito em julgado lance-se os seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República); oficie-se ao TRE; intime-se para pagamento da multa e expeça-se guia de execução definitiva.

Custas " ex lege".

P.R.I.

WALTER EMÍDIO DA SILVA
JUIZ DE DIREITO